

0005463-16.2021.8.26.0606

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Magistrado: Felipe de Melo Franco

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/11/2022

... desse E. Tribunal:

"Cartão de crédito - Roubo - Ocorrência deste comunicada a administradora, na mesma ocasião em que ocorreu, tendo sido efetuado o estorno de alguns dos saques impugnados - Estorno dos demais que também deveria ser feito, ainda que se refira a saques com senha pessoal - Falha na prestação dos serviços da ré evidenciada nesta hipótese Responsabilidade da prestadora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Paulo Portela, s/n, Suzano - SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0005463-16.2021.8.26.0606 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005463-16.2021.8.26.0606

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO-
Liquidação / Cumprimento / Execução-Obrigação de Fazer / Não Fazer

Requerente:

Carlos Bragheroli

Requerido:

Banco do Brasil S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Felipe de Melo Franco

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Concedo a justiça gratuita ao Autor.

Sem preliminares que revelem a carência das condições da ação e dos singelos pressupostos processuais, abrandados pela ótica exposta no disposto nos artigos 2º, 13, 14 e parágrafos, todos da Lei 9.099/95, com maior celeridade, concentração, economicidade e informalidade.

O pedido comporta julgamento imediato, independentemente da produção de outras provas, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Alega o Autor que, no dia 26/10/2021, quando estava no caixa eletrônico, localiza dentro de um supermercado, foi abordado por uma pessoa, que disse ter saído um papel do caixa, informando a necessidade de atualização. O Autor acreditou que o papel era legítimo, retornando ao caixa, para fazer o que estava sendo solicitado na tela. Porém, a máquina travou e prendeu seu cartão. Então, a pessoa que o havia

ajudado anteriormente, apertou uma tecla do caixa, destravando a tela e retirando o cartão do autor, que entregou a ele rapidamente. Entretanto, nesse momento, a pessoa trocou o cartão do Autor por outro.

Então, o Autor ligou no Banco Réu para pedir o bloqueio do cartão. Esse, por sua vez, o informou que já havia cancelado três compras no débito com valor aproximado de R\$ 9.000,00 e que uma compra no crédito com valor de R\$ 8.500.00 ainda estava em análise. O autor solicitou o cancelamento do seu cartão e a não autorização dessa última transação, uma vez que havia sido vítima de fraude. A atendente do Réu informou que havia feito o cancelamento e que não tinha autorizado a referida transação. Porém, no dia 06/11/2021, o Autor recebeu um SMS, informando que sua contestação foi indeferida e os valores seriam cobrados na próxima fatura. Assim, a fatura, com vencimento, em 04/12/2021 contém cobrança de parcela de R\$ 2.833,34, correspondente a 1/3 do valor contestado pelo Autor. Pede, ao fim, a concessão da gratuidade da Justiça, o cancelamento das cobranças derivadas da fraude que sofreu e indenização por danos morais.

Na decisão de fl. 25, foi deferida em parte a tutela de urgência para determinar ao Réu que se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento das compras supracitada, lançada na fatura de cartão nº 49844215.XXXX.1679, sob pena de incidir em multa, fixada em R\$ 6.000,00 em caso de descumprimento, o que não desobriga a parte autora de efetuar o pagamento dos demais valores relativos às operações que reconhece.

O Réu, em sua contestação, alega que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos narrados, tendo em vista que o autor aceitou a ajuda de terceiros e que os fatos ocorreram fora da agência bancária. Aduz que a simples posse do cartão não permitiria ao fraudador realizar qualquer saque ou transação, ou seja, ele teve acesso à senha pessoal e intransferível do autor. Por fim, afirma que houve culpa da vítima exclusiva e fato de terceiro, o que afasta a sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo Autor.

Inicialmente, cumpre salientar que a relação jurídica descrita nos autos se submete às regras dos artigos 12 e 14, do CDC, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo, pois, a presente demanda ser analisada sob o enfoque da responsabilidade objetiva. Ademais, exatamente em virtude das dificuldades de ordem técnica que recaem sobre a posição da parte consumidora, justifica-se plenamente a aplicação da norma do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova. De mais a mais, aplica-se às relações de consumo a teoria da responsabilidade objetiva nos casos de dano oriundo da falha na prestação do serviço, seja porque o serviço não funcionou, funcionou de forma ineficiente ou, ainda, tardiamente.

No presente caso, pela análise do conjunto probatório dos autos, restou demonstrada a falha nos serviços prestados pelo Réu, em especial, de segurança no procedimento das operações com cartão bancário. Isso porque, a simples análise da fatura de cartão de crédito do autor evidencia a discrepância do valor da operação impugnada com seu perfil de consumo (fls. 18), sendo o valor da dita operação infinitamente superior ao valor total de gastos mensais do autor.

Saliente-se que não se pretende aqui atribuir-se ao banco a responsabilidade pela conduta de eventual terceiro fraudador. Entretanto, não há como afastar a responsabilidade da instituição bancária pelos prejuízos acarretados ao autor, diante da falha do seu dever contratual de zelo e guarda pelo patrimônio de seus consumidores.

Se o banco permite e estimula que operações bancárias sejam efetuadas por cartões magnéticos, é porque algum benefício auferido com tal prática. Ao disponibilizar esta forma de movimentação, o banco obrigatoriamente se comprometeu a promover o monitoramento das transações realizadas desta forma, visando prevenir fraudes. Sendo assim, o fornecedor tem a obrigação de manter ambiente digital seguro de modo a evitar a ocorrência de fraudes. Diante disso, o Réu não comprovou que não houve fraude na operação ora impugnada.

Pois bem. O risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial. Se é certo que cabe ao consumidor, o

zelo e guarda de seu cartão e senhas pessoais, é certo também que cabe aos bancos agir e adotar medidas para impedir a conduta de terceiros fraudadores. É dele o dever de guarda do patrimônio de seus consumidores. Como o Réu não apresentou nenhum documento que comprovasse a compra pelo Autor, entende-se, que ele não realizou essa operação financeira, sendo dever do banco zelar pela segurança do sistema e, em caso de falha desde, reembolsar seus clientes.

E não há que se cogitar a hipótese de o réu se eximir de responsabilidade, com base nas excludentes de fato de terceiro. Isso porque, o Réu lucra ao vender a ideia de facilidade adicional representada pelo pagamento por intermédio de cartão, cujas operações são realizadas por meio de máquinas à disposição do consumidor, com evidente facilitação para o consumo dos produtos e consequente aumento da lucratividade. Tal forma facilitada de contratação que, é colocada no mercado pelo banco, entretanto, apresenta uma falha de segurança intrínseca, que é, exatamente, a de permitir que terceiros, em posse de cartão e senha pessoal obtidos criminosamente do correntista por fraude ou mediante ameaça, venham, em seu lugar, a realizar tais operações, sem que haja um mecanismo confiável de checagem de suas identidades.

Trata-se de ocorrência previsível e conhecida pelos bancos, que optam em manter tais serviços. Assim, se o sistema é fraudado maliciosamente por terceiros, causando danos ao consumidor, a reparação destes é de responsabilidade do fornecedor, não se aplicando a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, por se tratar de risco previsível e inerente ao próprio negócio, fortuito interno, que não afasta a responsabilidade civil do Réu.

A questão foi pacificada pelo STJ em sua súmula nº 479, "in verbis":

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"

Pontua-se que a responsabilidade do banco é amplamente reconhecida quando a senha e o cartão do correntista são obtidas através de fraude. Isso porque, trata-se de forma previsível de burla ao sistema colocado no mercado pela instituição financeira, que por sua segurança deve se responsabilizar. Logo, é de rigor a condenação do réu a indenizar o autor pelos danos materiais que sofreu em decorrência das compras realizadas por força da fraude.

Nesse sentido, jurisprudência desse E. Tribunal:

"Cartão de crédito - Roubo - Ocorrência deste comunicada a administradora, na mesma ocasião em que ocorreu, tendo sido efetuado o estorno de alguns dos saques impugnados - Estorno dos demais que também deveria ser feito, ainda que se refira a saques com senha pessoal - Falha na prestação dos serviços da ré evidenciada nesta hipótese Responsabilidade da prestadora de serviço configurada nos termos do art. 14 do CDC, também aplicável no caso vertente - Descabimento da invocação de restrição prevista no contrato de seguro do cartão(card protection), mesmo porque não demonstrado que teria sido devidamente informada ao contratante, consoante previsto, também, em referido Código - Ação anulatória de débito que deve ser julgada procedente - Recurso dos autores provido para tanto." (TJSP; Ap. 9122954-27.2002; 14ª Câm. D. Privado; rel. Thiago deSiqueira; j. 04/05/11).

Diante disso, o Banco Réu deve cancelar a cobrança indevida feita ao Autor no valor de R\$ 8.500,00 e devolver os valores que eventualmente já tenham sido pagos. Ainda mais porque, o Autor comunicou a fraude ao Banco, que cancelou as compras realizadas pelos fraudadores no débito, mas não cancelou a compra aqui discutida, que foi realizada no crédito.

Quanto aos danos morais, é importante destacar que, no caso dos autos, houve um ato de terceiro desencadeador dos fatos. A falha de serviço do Réu não é atinente ao fato de terceiro, mas apenas desacordo sobre a responsabilidade pelos danos causados pela fraude perpetrada por terceiro, um debate factual e tecno-jurídico. O Réu não responde pelos danos psicológicos frutos do ato de terceiro, inclusive neste ponto (primeiro fato) poderia se pensar em falha do autor, mas sim e apenas pelo debate e recusa de cancelamento superveniente da operação causada por terceiro por conta do débito fugir do perfil do cliente (e não pela fraude e seus impactos). Esta recusa é mero desacerto sobre responsabilidade contratual pelos danos dos

fatos de terceiro, não havendo razão para condenar o Réu ao reparo dos danos morais, lembrando que o Réu terá que arcar com os danos próprios da relação contratual.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para conceder a justiça gratuita ao Autor e para declarar a inexigibilidade do valor de R\$ 8.500,00, referente a compra no crédito realizada no cartão do autor no dia 26/10/2021. No caso de ter havido pagamento, dever o Réu devolver o valor debitado com correção monetária pelo IPCA-E desde a data do desembolso e juros de mora de 1% desde a citação.

Não há condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual.

O prazo para recorrer desta sentença é de 10 dias úteis a contar da intimação, obrigatoriamente através de advogado e, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 bem como do Comunicado CG 1530/2021, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária gratuita, deve vir acompanhado de comprovação do recolhimento do preparo, o qual compreende todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, etc), inclusive as dispensadas em primeiro grau.

Em caso de ter sido realizada audiência conciliatória na qual foram fixados honorários ao conciliador, a parte recorrente deve pagá-los, no valor contido no termo expedido, com fundamento legal nos artigos 55 da Lei nº 9.099/95, 13 da Lei 13.140 e 169, § 1ª do Código de Processo Civil, regulamentados pelas Resoluções números 809/2019 do TJSP e 125/2010 do CNJ, valor este que também é considerado como despesa processual.

O recolhimento dos honorários do Sr.(a) Conciliador(a) deverá ser realizado através de depósito judicial vinculado a este processo (utilizar o portal de custas do site do TJ/SP fazendo constar no campo de observação: ref. Honorários de Conciliador).

Nos termos da Lei Estadual nº 15.855/2015, do artigo 54, parágrafo único; da Lei nº 9.099/95, bem como do Comunicado CG nº 489/2022, o valor do preparo deverá ser composto pela soma das seguintes parcelas: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). As parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE, observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça nº 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento.

O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

O valor do preparo e dos honorários do conciliador devem ser recolhidos no prazo de até 48 horas após a interposição do recurso, independentemente de intimação. Não existe possibilidade de complementação, caso haja recolhimento de valor inferior ao devido, conforme restou pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg na Rel 4.885/PE).

Para início da fase de cumprimento de sentença, o peticionamento deverá observar os termos do Comunicado CG nº 1789/2017.

Para fins de execução da presente sentença, deverá o exequente apresentar em cartório cálculo atualizado do débito, o que poderá ser realizado através do sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no link <http://www.tjsp.jus.br/PrimeiraInstancia/CalculosJudiciais/Comunicado?codigoComunicado=339&pagina=1>.

P.I.C

Suzano, 26 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA